

1501425-05.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... foi processado duas vezes antes por tráfico, sendo condenado numa delas, mas, nessas outras ocasiões tinha se dirigido até o local para comprar drogas.

A confissão foi corroborada pela prova produzida.

O policial civil Fábio Luís relatou que estavam com uma viatura descaracterizada e se deslocaram até uma praça conhecida como ponto de tráfico no bairro CECAP. Então,

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501425-05.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501425-05.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248761/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 20209421

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FÁBIO LUIS DE PAIVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisela Ruffo

Vistos.

FÁBIO LUÍS DE PAIVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2021, por volta de 11h30min, na praça pública localizada na Alameda João Batista Camargo Mendes, próximo ao nº 40, bairro CECAP, nesta cidade e comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 22 (vinte e dois) invólucros plásticos incolores, fechados por nós, formando "fiadas", contendo cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 1,2g (um grama e dois decigramas), e 12 (doze) invólucros plásticos, do tipo "filme", contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 12,7g (doze gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes e que

determinam dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais civis, em uma viatura descaracterizada, encontravam-se no local do ocorrido, que é conhecido como “ponto” de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado praticando atos característicos de comercialização de droga, quais sejam, mantinha contatos furtivos com transeuntes, ia até uma árvore, pegava algo em um galho e o entregava para o transeunte, que deixava o local. Diante disto, os policiais abordaram o réu, o qual admitiu que estava comercializando drogas e que as ocultava em um maço de cigarros, preso a um galho de uma árvore, indicando o local. Realizada busca na árvore indicada, foi localizado um maço de cigarros, contendo vinte e duas “pedras” de “crack” e doze porções de “maconha”, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 98) e apresentou defesa preliminar (fls. 102/106), seguindo-se a decisão de fls. 107/109, que recebeu a denúncia em 26.11.2021.

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pela fotografia de fls. 13 e pelo laudo de fls. 71/73, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, afirmou que realmente estava vendendo drogas em razão de uma represália que tinha levado por estar devendo para o pessoal do comando. Afirmou que eles ameaçaram entrar na sua casa e pegar alguma coisa para pagar a dívida. Então, como tem pais idosos, acabou assumindo o risco de vender a droga para pagar o dinheiro que devia para eles. Disse que foi a única vez que aconteceu isso na sua vida. Afirmou que foi processado duas vezes antes por tráfico, sendo condenado numa delas, mas, nessas outras ocasiões tinha se dirigido até o local para comprar drogas.

A confissão foi corroborada pela prova produzida.

O policial civil Fábio Luís relatou que estavam com uma viatura descaracterizada e se deslocaram até uma praça conhecida como ponto de tráfico no bairro CECAP. Então, notaram um indivíduo em atitude suspeita. Atestou que uma mulher foi até ele e, após, ele pegou algo numa árvore e entregou para ela. Logo em seguida, chegou outra mulher e a ação se repetiu, em atividade típica de tráfico. Asseverou que abordaram o réu e o questionaram sobre a droga que ele estava vendendo, tendo ele, de pronto, admitido a prática do crime e indicado onde estava o entorpecente, num maço de cigarros preso a uma árvore. Informou que, nesse maço, havia 22 pedras de crack, 12 porções de maconha e duas cédulas de R\$ 5,00, que ele afirmou serem proveniente das duas vendas que ele acabara de fazer.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil André Augusto.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E “como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial” (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto

outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais terem flagrado o réu em atividades típicas da traficância, vindo a apreender um maço de cigarros contendo vinte e duas pedras de "crack" e doze porções de maconha, em local por ele indicado, aliado à confissão, conduz à certeza quanto à autoria e a traficância.

Anoto que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliados à forma como estavam acondicionados, ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e as circunstâncias da apreensão, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno que não inocenta o réu a alegação de que teria sido ameaçado em razão de dívida de drogas e, por isso, estava traficando. A uma porque não foi amparada por qualquer elemento de prova. A duas porque a ausência de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa reclama, para sua configuração, que o sujeito não possa praticar comportamento diverso do que o vedado por lei, o que não acontece quando alguém se diz impelido a traficar porque alguém a determinou que fizesse, pois, ainda que verdadeira a alegação, podia abster-se da prática criminosa.

Sobre o tema o seguinte julgado: Apelação Criminal nº 1525099-29.2019.8.26.0228, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 15.04.20; Apelação Criminal nº 0002812-52.2018.8.26.0400, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 14.04.20 14, e Apelação Criminal nº 1500428-95.2018.8.26.0544, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 12.05.20.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498). Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, anoto que há processo em andamento contra o réu, pela prática de crime da mesma natureza, no qual foi inclusive proferida sentença condenatória (autos 1500584-10.2021 da 2ª Vara Criminal local - fls. 129/130). Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, por intermédio da aprovação da Súmula nº 444, de que inquéritos policiais e ações penais ainda em andamento não podem ser considerados para fixar a pena-base do agente acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da

não culpabilidade. Confira-se o teor da referida súmula: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base".

De outra banda, o réu ostenta condenação transitada em julgado, pela prática de crime (autos 1501236-61.2020 da 2ª Vara Criminal local - fls. 123), a qual, embora não induza à reincidência, dada a data do trânsito, caracteriza Maus antecedentes. Consigno que, para o reconhecimento dos Maus antecedentes, não se exige, como para a reincidência, que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior ao crime tratado, bastando que a condenação decorra de fato ocorrido anteriormente.

Não importa que tenha o trânsito em julgado da condenação ocorrido depois dos eventos analisados nos presentes autos, pois o que se exige para a configuração dos Maus antecedentes é que o fato seja anterior e que a condenação seja definitiva, a fim de se evitar qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência (cf. Apelação nº 0001448-64.2017.8.26.0599, Rel. Des. Newton Neves, j. 22.02.19).

No mesmo sentido já decidiu o E. STJ: "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar Maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018).

Porém, considerando que, nos autos da condenação respectiva, dando o réu como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, foi aplicada tão-somente medida de advertência, reputo contrário ao princípio da proporcionalidade do direito penal, aumentar a pena ora imposta, porquanto implicaria punição maior do que a aplicada por conta da própria infração anterior.

Assim, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Inexistem causas de aumento. De outro lado, o réu não faz jus à redução prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. O § 4º do art. 33, tem a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada, pressupondo não disponha o réu sinais indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando com profissionalismo. O redutor incide na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (cf. Apelação nº 990.09.155655-6, Rel. Des. Luis Antonio Cardoso, j. 29.6.2010).

No caso dos autos, verifica-se que o réu responde a processo pela prática de delito da mesma espécie, na qual foi proferida sentença condenatória, o que indica que seu envolvimento com atividade criminosa não é meramente ocasional.

Embora não se mostrem válidos para aferir os Maus antecedentes e a reincidência, os inquéritos e processos em andamento são hábeis para não aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"...CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. (...) 5. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e que não se dedique a atividades delituosas. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 6. Certo é que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possuem o condão de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal. Essa, aliás, é a essência do princípio da presunção de não culpabilidade. Contudo, não há óbice a que processos em andamento ou mesmo condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva

(ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas. 7. O registro de feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade podem afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador, quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, mas pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa. 8. É possível que o julgador que, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, possa livremente valorar as provas carreadas aos autos e os demais dados constantes do processo inclusive os depoimentos de testemunhas ou mesmo a confissão do acusado para, se for o caso, se convencer de que o agente não é merecedor do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se dedicar a atividades criminosas..." (STJ HC 338.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.12.2016).

Ademais, o réu já foi condenado como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/06, com sentença transitada em julgado.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena de reclusão, fixo o fechado, único compatível com a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, condenando FÁBIO LUÍS DE PAIVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade. Recomendem-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Piracicaba, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA